第九章 正当行为

第一节 正当行为概述

【考点 1：正当行为概念与特征】

（1）正当行为又称_____，指客观上造成损害结果，形式上符合某犯罪客观构成要件，但实质上不具有_____和刑事违法性的行为；

（2）第一特征：形式上符合某种犯罪的_____，会对实施对象造成一定____；

（3）第二特征：实质上不符合犯罪构成特征，主观上为保护_____，不具备犯罪客体、犯罪主观要件等；

〈示例〉正当防卫对不法侵害人造成损害，紧急避险使某种合法权益受损害；

【考点 2：正当行为种类】

（1）刑法明文规定：_____和_____两种；

（2）其他正当行为包括：_____；正当业务行为（医疗行为和竞技行为）；（直接依法实施的行为和执行命令的行为）；基于权利人承诺或自愿的损害行为；

【考点 3：研究正当行为的意义】

（1）实践层面：有助于_____中区分正当行为与相关犯罪行为，保证不具有社会危害性的行为不受_____追究；

（2）理论层面：有助于理解刑法_____和犯罪本质属性，掌握犯罪构成基本理论，把握_____界限；

（3）社会效果层面：_____行使法律权利，进行正当防卫、紧急避险，积极与违法犯罪行为作____；

第二节 正当防卫

【考点 1：正当防卫的概念与特征】

（1）正当防卫是指为了使_____、本人或他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害，而对不法侵害者实施的制止其不法侵害且未明显超过造成重大损害的行为；

考研你终硕 制作

（2）具有_____等行为表现，通过对不法侵害人的_____实施；

（3）是针对不法侵害行为的正当、合法的_____行为，受国家法律保护、支持和____；

【考点 2：正当防卫的五个成立条件】

（1）目的条件：必须是为了保护_____，包括国家利益、社会公共利益、本人或他人的各种权益；

（2）起因条件：必须存在正在进行的_____行为；

（3）时间条件：不法侵害必须_____，已经开始且尚未结束；

（4）对象条件：防卫针对的必须是_____及其____；

（5）限度条件：防卫行为不能明显超过_____而造成_____；

【考点 3：目的条件的排除情形】

（1）防卫挑拨：行为人故意_____对方先行侵害，然后借口正当防卫加害对方，实质是有____的不法侵害行为；

（2）互殴行为：双方都出于侵害对方的_____而互相侵害，均为不法侵害人，不享有_____；

（3）偶然防卫：行为人故意实施侵害时偶遇他人不法侵害，客观上制止了侵害但主观无_____；

〈注意〉互殴中一方放弃侵害、退让逃避时，另一方继续攻击的，放弃方可进行正当防卫；

【考点 4：起因条件的具体要求】

（1）不法侵害既包括_____也包括_____，但应具有暴力性、破坏性和特征；

（2）不法侵害必须具有_____，对合法行为不能实施正当防卫；

（3）不法侵害必须_____，基于认识错误的假想防卫按_____处理；

〈案例〉执法人员的拘捕、搜查、扣押行为，人民群众的扭送行为，正当防卫、紧急避险行为等均为合法行为；

bilibili 考研小硕 制作

〈注意〉动物"自发"侵袭属紧急避险；动物受人驱使侵袭他人，可对驱使人或动物进行正当防卫；

【考点 5：特殊主体的侵害行为】

（1）未达刑事责任年龄的_____、无刑事责任能力的_____自发侵害，明知其无责任能力的不能正当防卫，可_____；

（2）不知其无责任能力而反击的，属_____，按_____认定；

（3）在他人____下实施侵害的，反击行为属_____；

〈引述〉"成年人对于未成年人正在实施的针对其他未成年人的不法侵害，应当劝阻、制止；劝阻、制止无效的，可以实行防卫"；

【考点 6：时间条件的具体把握】

（1）不法侵害已经开始：侵害人已_____侵害行为，或形成现实、_____；

（2）不法侵害尚未结束：侵害行为或_____仍在继续，可用防卫手段制止或____；

（3）不法侵害结束的四种情况：_____、危害结果已造成且_____、侵害被制止且侵害人被控制、侵害人丧失继续侵害能力；

〈易错点〉防卫不适时分为事前防卫和事后防卫，均不符合时间条件；事前防卫属"先发制人"，事后防卫多为报复性侵害；

【考点 7：限度条件的判断标准】

（1）应_____不法侵害的性质、手段、强度、危害程度和防卫的时机、手段、____、_____等情节；

（2）考虑双方_____，立足防卫人防卫时所处____，结合社会公众一般认知判断；

（3）不应____防卫人采取与不法侵害_____的反击方式和强度；

〈注意〉不能简单将防卫损害与侵害损害进行量上比较，要求基本相等；

bilibili 考研你终硕 制作

【考点 8：特殊防卫（无限防卫）】

（1）适用条件：针对正在进行的____、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的_____；

（2）_____，造成不法侵害人伤亡的不属_____，不负刑事责任；

（3）"严重危及人身安全的暴力犯罪"既____"其他"行为，也修饰前述_____；

〈注意〉采取隐蔽性、非暴力手段的杀人、抢劫等不适用特殊防卫，如投毒杀人、麻醉抢劫；

【考点 9：行凶的认定标准】

（1）使用_____，严重危及他人人身安全的；

（2）未使用凶器或致命性凶器，但根据侵害人数、_____和力度等情况，确已严重危及他人人身安全的；

（3）虽未造成实际损害，但已对人身安全造成严重、_____的；

【考点 10：防卫过当的概念与责任】

（1）防卫过当是指防卫明显超过必要限度造成_____，应当负刑事责任的行为；

（2）罪过形式只能是_____或____，不能是直接故意；

（3）定罪时依据主观罪过形式和客观行为性质确定____，分别以过失致人死亡罪、故意杀人罪等定性；

（4）量刑时应当____或者_____，一般先考虑减轻处罚；

〈时序〉2016 年于欢案、2018 年昆山反杀案、福建赵宇案等引发社会关注，正当防卫制度被"唤醒"；2020 年 8 月 28 日"两高一部"印发《关于依法适用正当防卫制度的指导意见》；

〈引述〉"要切实防止'谁能闹谁有理''谁死伤谁有理'的错误做法，坚决捍卫'法不能向不法让步'的法治精神"；

第三节 紧急避险

【考点 1：紧急避险的概念与特征】

（1）紧急避险是为了使国家、公共利益、本人或他人的人身、财产和其他权利免受正在发生的危险，不得已而采取的损害另一_____的行为；

考研你终硕 制作

（2）具有伤害人身、_____的行为表现；

（3）是有益于社会公共秩序的行为，应受到____和支持；

（4）是避险人在已无可能采取其他措施时不得已采取的_____，主观上不具有危害社会的罪过；

【考点 2：紧急避险的成立条件】

（1）起因条件：合法权益遭受损害危险，危险来源包括人的不法侵害行为、_____、_____、人的生理疾患；

（2）时间条件：危险正在发生，对合法权益形成____、____的危险；

（3）对象条件：避险行为损害的是除避险人和不法侵害人以外的_____的合法权益；

（4）目的条件：行为人主观上必须有正当的_____；

（5）限度条件：避险行为不能超过必要限度，造成的损害必须____所避免的损害；

（6）限制条件：避险行为必须在_____的情况下才能实施；

〈示例〉饥渴难耐的旅行者在物主不在时私自取走路边房屋中的饮食；为抢救重伤员强行拦截过往汽车送往医院；

〈注意〉危险必须是客观现实存在的，不能是避险人凭主观想象臆造和推测的；

〈易错点〉假想避险不是紧急避险，应依据对事实认识错误的原理处理；

【考点 3：特殊主体的限制】

（1）关于避免本人危险的规定，不适用于职务上、业务上负有_____的人；

（2）负有特定责任的人即使无法排除危险也不能进行紧急避险，必须_____；

〈示例〉军人面对战死沙场危险仍须参加战斗；消防队员面对烈火危险仍须救火；民航机组成员面对坠机危险仍须坚守岗位；

〈注意〉强调的是"负有特定责任的人"，不是"具有职务或从事业务的人"；

【考点 4：避险过当及其刑事责任】

（1）避险过当是指避险行为超过必要限度造成_____，应当负刑事责任的行为；

（2）罪过形式通常是_____，少数情况下可能是间接故意或过于自信的过失；

（3）定罪时应依据主观罪过形式和客观行为性质按刑法分则_____定罪；

（4）量刑时应当____或者_____；

〈注意〉避险过当本身不是独立罪名，刑法分则也没有规定独立的法定刑；

【考点 5：紧急避险与正当防卫的区别】

（1）起因条件：正当防卫仅限于人的不法侵害，紧急避险包括人的不法侵害、自然灾害、_____、人的生理疾患；

（2）对象条件：正当防卫只能针对_____实施，紧急避险必须针对实施；

（3）限度条件：正当防卫是制止不法侵害所必需，紧急避险造成的损害只能所避免的损害；

（4）限制条件：正当防卫面对正在进行的不法侵害就可实施，紧急避险只有在情况下才能实施；

（5）主体要求：负有特定责任的人不能为避免本人危险而实施_____；

第四节 其他正当行为

【考点 1：自救行为】

（1）_____是权利受到侵害的人在无法按照正式法律程序等待国家公权力救济时，以自己力量求得_____的行为；

（2）_____：不法侵害已对自救人合法权益造成侵害；通过法律程序来不及或不可能恢复权益；主观上具有自救目的；自救行为具有_____；

（3）若自救行为所侵害权益明显超过被恢复权益，则不具_____，不能排除_____；

〈示例〉盗窃罪被害人在犯罪人将要损毁盗窃财物或逃往外地时，来不及通过法律程序挽回损失，迅速从盗窃犯手中夺回财物的行为；

〈注意〉不法侵害正在进行时应认定为正当防卫或紧急避险，而非自救行为；

【考点 2：正当业务行为】

（1）_____是行为人根据自身从事职业要求所实施的行为，虽给他人造成身体伤害但不具_____；

（2）_____：从事业务合法且行为人具备专业知识和业务能力；主观上具有有益于社会的正当目的；行为没有超出_____；

（3）违反操作规程或超出保全合法权益必要限度造成不应有损害的，不属于_____；

〈示例〉医生实施的医疗行为、职业拳击手实施的竞技行为；

【考点 3：法令行为】

（1）_____是根据有效法律法规或上级组织命令实施的合法行为，分为依照法律实施的行为和_____的行为两类；

（2）依照法律实施行为的_____：具有明确法律法规依据；主观上具有有益于社会的正当目的；行为在法律规定_____；

（3）执行命令行为的_____：命令是所属上级依照职权经法定程序依法发布；明确认识命令的合法有效性和有益性；执行行为在_____；

〈示例〉警察依法处决死刑犯、拘留逮捕搜查犯罪嫌疑人；士兵依据长官命令击毙敌军士兵；

【考点 4：基于权利人承诺或自愿的损害行为】

（1）基于_____的损害行为是经有权处理某种权益的权利人同意后实施的的行为；

（2）_____：权利人有权处理其合法权益；权利人同意是自愿的；权利人同意是合法或合乎道德的；权利人同意是有益于社会的；行为在权利人_____且没有超出必要限度；

（3）任何人实施"_____"行为都构成犯罪，但主观出于善良动机且未造成恶劣影响的可酌情从轻或_____；

〈示例〉为科学实验，权利人同意他人将自己关闭起来，在一定时间内自愿放弃行动自由；

〈注意〉刑法没有明确排除实施"安乐死"行为的犯罪性；